

1509455-61.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... nº 11.343/06, com o afastamento do "tráfico privilegiado", fixando-se os regimes iniciais fechado (tráfico) e semiaberto (favorecimento real).

Já a D. Defesa às fls. 201/207 pleiteou, em síntese, pela ausência de materialidade ou atipicidade do delito de favorecimento real ou o reconhecimento do delito tentado, e no que tange ao tráfico, a absolvição por ausência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509455-61.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509455-61.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2318406/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 15747243 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 2109/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2318406 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER ROBERTO ADORNO DA MATA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Wagner Roberto Adorno da Mata, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06 em concurso material com o art. 349-A do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 24 de maio de 2021, às 10h, no CPP I de Bauru, situado às margens da Rodovia SP 300, km 350, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 8 aparelhos celulares no estabelecimento prisional, sem autorização legal.

Ainda, segundo a inicial, o acusado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, foi surpreendido com 100 segmentos de papel do tipo "picote" ou 4,01 gramas de droga sintética 25E-NBOH, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), laudo definitivo (fls. 15/18), relatório conclusivo (fls. 68/77).

Pela decisão de fls. 84/86 foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 102), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 106).

Na decisão de fls. 111/112, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 178/180, foram ouvidas as testemunhas e foi interrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 194/198 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a valoração do art. 42 da Lei Antidrogas, a constatação dos maus antecedentes e personalidade transviada, além das agravantes da multirreincidência e do "estado pandêmico", o reconhecimento da confissão quanto ao favorecimento real, além da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei nº 11.343/06, com o afastamento do "tráfico privilegiado", fixando-se os regimes iniciais fechado (tráfico) e semiaberto (favorecimento real).

Já a D. Defesa às fls. 201/207 pleiteou, em síntese, pela ausência de materialidade ou atipicidade do delito de favorecimento real ou o reconhecimento do delito tentado, e no que tange ao tráfico, a absolvição por ausência de provas, ou o lançamento das penas nos patamares mínimos, e fixação de regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), laudo definitivo (fls. 15/18), relatório conclusivo (fls. 68/77).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os agentes penitenciários Cláudio Tetsuo Ueti e Wilson Hajimi Izumi, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que ao retornar de sua saída temporária, o acusado passou pelo scanner corporal, ocasião em que foram encontrados celulares e micropontos de drogas no ânus dele. Afirmaram que o próprio réu entregou espontaneamente os materiais e, por isso, confessou o delito.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na

condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Wagner Roberto Adorno da Mata sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou a prática da infração penal de favorecimento real. Disse que tentou entrar na penitenciária com celulares e chips, sem portar drogas. Afirmou que estava 'de saída temporária'.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação por ambos os delitos.

Com efeito, diversamente do alegado pela D. Defesa, foram apreendidos quarenta chips e oito mini celulares (fls. 11/12).

É o que se extrai, ainda, das imagens de fls. 28/31.

Por isso, a materialidade está evidenciada, já que despicienda a perícia nos chips ou nos aparelhos apreendidos.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEP (POSSE DE APARELHO CELULAR). INDISCIPLINA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após cuidadoso exame dos autos e com base no princípio do livre convencimento motivado, considerou haver prova suficiente acerca da falta cometida pelo apenado. Logo, conclusão em sentido diverso implicaria revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela via estreita do habeas corpus.

2. "Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade (AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 760894 / RS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 14/11/2022)

De outro lado, em que pese a negativa do acusado, as drogas foram apreendidas também durante a checagem no scanner, mais precisamente no ânus do réu, com a seguinte descrição pericial: DETECTADA presença da substância 25E-NBOH no material acima descrito. Cabe consignar que a mencionada substância encontra-se relacionada na Lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06 e art. 349-A do Código Penal, em concurso material.

Passo à fixação da pena.

Favorecimento real especial (art. 349-A do Código Penal)

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos nº 0005777-57.2010 e 4663-83.2007 (fls. 120/145 e 160/171)

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade é acentuada, visto que o delito foi cometido quando em benefício de saída temporária.

As circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve ser exasperada em 1/2, atingindo 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência

majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na intermediária, o acusado é multirreincidente.

São os feitos: 0005505-92.2009, 0002061-22.2007, 0008078-98.2012, 0003819-65.2009, 0005537-97.2009, 0002543-91.2012, 0005123-366.2008, 0006982-19.2010 e 0002377-30.2010, ou seja, 9 (nove) no total.

Deste modo, ainda que a confissão se compense com uma delas, deve a pena ser duplicada, atingindo 3 (três) meses de detenção.

Na final, entendo que o delito foi tentado.

O acusado foi surpreendido no scanner, quando tentava entrar com os objetos para deles dispor.

Contudo, é notório que o próprio scanner é a última proteção, no aspecto, ao presídio.

Em outras palavras, a iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade.

Por isso, a reprimenda deve ser diminuída em 1/3, totalizando 1 (um) mês de detenção.

Tráfico de drogas (art. 33 “caput” da Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos nº 0005777-57.2010 e 4663-83.2007 (fls. 120/145 e 160/171)

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade é acentuada, visto que o delito foi cometido quando gozava de saída temporária.

As circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Em acréscimo, a natureza (25E-NBOH), circunstâncias que denotam que a pena deve ser exasperada em 1/2, perfazendo 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, como argumentado, inaplicável a agravante do "estado pandêmico". Ainda na intermediária, o acusado é multirreincidente.

Assim, a pena é aumentada de 1/5, atingindo 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Na derradeira, deve ser valorada a causa de aumento descrita no art. 40, III da Lei Antidrogas, seja pela multinuclearidade da infração, bem como, pela majorante restar caracterizada com a traficância ainda que "nas imediações".

Portanto, a reprimenda é aumentada em 1/6, totalizando, em definitivo, 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do acusado.

Os bens jurídicos diversos atraem a regra do concurso material, sem, entretanto, repercutir na reprimenda, pela natureza diversa.

Fixo o regime inicial fechado para o tráfico e inicial semiaberto para o favorecimento real.

O réu é multirreincidente.

Além disso, as circunstâncias judiciais não foram consideradas inteiramente favoráveis.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais

prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, deste modo:

CONDENO o acusado Wagner Roberto Adorno da Mata, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração descrita no art. 349-A c.c. 14, II, ambos do Código Penal;

CONDENO o acusado Wagner Roberto Adorno da Mata, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo, pela prática da infração descrita no art. 33 "caput" c.c. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Quanto aos aparelhos celulares, chips, metal e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA